

1524075-92.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1524075-92.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524075-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Yuri Guimarães da Silva Felipe

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos etc.

Richard Yuri Guimarães da Silva Felipe, qualificado à f. 9, menor de vinte e um anos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, porque em 3 de outubro de 2021, por volta das 10h30, em período de calamidade pública, na Rua Professor Flaminio Fávero, altura do nº 32, bairro Jardim Helena, nesta cidade e Comarca de São Paulo, transportava 985 porções variadas de cocaína, com peso líquido de 500,5 g (quinhentas gramas e cinco decigramas) e 1107 porções variadas de tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 2.434,3 g (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro gramas e três decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado deixou uma residência, transportando em uma mochila os entorpecentes acima descritos. Ocorre que Policiais Militares passavam pelo local e notaram que o denunciado, ao notar a presença da viatura policial, demonstrou certo nervosismo, surgindo assim a fundada suspeita para a abordagem que foi exitosa. No interior da mochila que o denunciado trazia consigo foi encontrada uma bolsa

bicolor, nas cores preta e branca, sendo que no interior de ambos os acessórios (mochila e bolsa) foram apreendidos, ao todo, 985 porções variadas de cocaína e 1107 porções variadas de maconha, além de um simulacro de arma de fogo e um caderno pautado contendo anotações de contabilidade do tráfico.

Informalmente, o réu admitiu a traficância, mas não quis dizer o nome do fornecedor do entorpecente. Autuado em flagrante delito, quando de seu formal interrogatório pela autoridade policial, não quis se manifestar sobre os fatos, bem como se recusou a fornecer material caligráfico.

Por fim, o crime de tráfico de drogas foi praticado quando já vigorava o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, decreto este que "Reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas".

Denúncia recebida (fls. 120/121), o réu foi citado (f. 162), e a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar (f. 172), em seguida advogado peticionou nos autos, sendo declarada preclusa a segunda defesa preliminar (fls. 199/203 e 208).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa sustentou aplicação de pena mínima, observadas as circunstâncias atenuantes de confissão judicial espontânea e menoridade relativa ao tempo do fato, bem assim, que o acusado simplesmente aceitou guardar a droga para algum traficante, não demonstrando envolvimento anterior com a criminalidade organizada. Este o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão relaciona um simulacro de arma de fogo, um bloco de anotações, 1107 porções de maconha e 985 porções de cocaína (f. 18).

Auto de constatação prévia de substâncias entorpecentes indica quinhentos gramas e cinco decigramas de cocaína, e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro gramas e três decigramas de maconha (fls. 34/37).

Laudo de exame químico toxicológico indica resultados positivos para tetrahidrocanabinol e cocaína (fls.174/176).

Laudo de exame de objeto não identificou manuscritos no bloco de anotações apreendido (fls. 177/180).

Em audiência de instrução:

Policial Militar Rafael do Carmo relatou que durante patrulhamento, em praça conhecida como ponto de tráfico, viu o réu saindo pelo portão de uma residência, com uma mochila nas costas e uma bolsa nas mãos, sendo logo abordado, não esboçando reação. As bolsas continham cocaína e maconha, em grandes quantidades, "já estava fracionada, acima de mil". Ao ser abordado inicialmente ele nada alegou sobre as drogas. Ele trazia também uma réplica de arma de fogo, não se recordando se havia um caderno com anotações. Ele foi abordado ao lado da residência dos familiares, em seguida, a mãe dele saiu da casa ao lado da qual ele havia saído, portanto, a casa de onde ele saiu não era a mesma casa da mãe dele. Por fim, desfez seu relato inicial no sentido de que ele teria confessado informalmente envolvimento com tráfico de drogas.

Policial Militar Wellington Tiago da Silva, no mesmo sentido, relatou que o réu foi abordado assim que abriu o portão de sua residência, que não tinha cadeado e ficava destrancado, carregando duas mochilas, e verificou-se que ambas continham drogas, sendo que ele não confessou informalmente o tráfico, dizendo apenas que ostentava passagem anterior. Em seguida, a mãe saiu de outra casa. "Ele estava descendo de um sobrado, a casa da mãe dele fica à esquerda, a segunda casa". Na condução do réu para a delegacia, contou as drogas, encontrando 985 porções de cocaína e 1107 de maconha. Foi apreendida também uma réplica de garrucha antiga. Não se recorda de caderno com anotações.

Ambos identificaram o réu em audiência.

Interrogado ao final da instrução, o réu confessou que guardava as drogas em sua residência, há uma semana, mediante pagamento de quinhentos reais, mas sua esposa pediu que retirasse as drogas, e na data dos fatos, os policiais entraram em sua

casa, encontraram a porta aberta, e recolheram as drogas, quando sua esposa não se encontrava, mais adiante, informou que as drogas estavam em sua casa desde a sexta-feira anteriormente à sua prisão que aconteceu no domingo.

Portanto, contrariou os depoimentos dos policiais, que em relatos uníssonos, confirmaram que o réu foi detido ao sair pelo portão da casa, que, ademais, situa-se ao lado da casa da mãe dele, que saiu em seguida e chegou conversar com os policiais para inteirar-se dos fatos, e apesar disso, não foi trazida pela defesa para confirmar a suposta invasão de residência dita pelo réu em interrogatório judicial.

Ausente, pois, circunstância atenuante de confissão judicial espontânea.

Neste contexto, a prova da apreensão das drogas resulta dos relatos dos policiais, contra os quais não consta nenhum outro elemento de prova, sendo que, se de fato havia mais alguém no local dos fatos, familiar do réu, cumpria à defesa arrolar como testemunha, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos.

Reporto-me ao entendimento jurisprudencial: Prova criminal - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313. Crime contra a saúde pública - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423.

Em interrogatório judicial, o réu sugeriu que os policiais teriam invadido sua residência sem autorização dos moradores para procederem a apreensão, apesar da defesa não ter arguido qualquer nulidade. Não obstante, a fim de eliminar possível arguição de nulidade do julgamento em instância recursal, esclareço que o julgamento recente a que alude tal tese, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sobre a exigência de gravação de imagens ou autorização escrita do réu para que os policiais ingressassem em sua residência, ainda que em situação de flagrante de crime permanente, não recebeu efeitos gerais ou vinculantes, e contraria entendimento consolidado há décadas pelo mesmo tribunal, divergindo inclusive do entendimento atual da 5ª Turma, no sentido de que o crime de tráfico, conduta de caráter permanente, consuma-se antes mesmo da interferência dos policiais, nas modalidades típicas guardar e trazer entorpecentes, para posterior entrega de qualquer forma a terceiros. A mesma temática já foi abordada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC 53.659, circunstância que afasta qualquer ilicitude a macular a prova produzida.

Nesse sentido: "Violação de domicílio - Inocorrência - Ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência, em que se realizava comércio ilícito de entorpecente - Garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio que é inaplicável nos casos de flagrante delito - Inteligência do art. 5º, XI da Constituição Federal. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio cede espaço nos casos de flagrante delito (CF, art. 5º, XI), não merecendo censura a ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência em que se realizava comércio ilícito de entorpecente, em especial quando a entrada ocorreu sem arrombamento." (STJ - RT 771/565).

Em julgamento mais recente, publicação DJe 08/04/2021, a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou entendimento contrário ao julgado invocado pela defesa, do qual destaco trecho específico sobre o tema questionado:

AgRg no RHC 143123/MG, Relator Ministro Félix Fischer; Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. II - O estado

flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses."

No mais, quanto ao elemento subjetivo do crime atribuído ao réu, inequivocamente manter em depósito centenas de porções de drogas variadas caracteriza prova de mercancia ilícita, mesmo porque, o próprio réu afastou a possibilidade da droga destinar-se a consumo pessoal.

Procedente a ação penal, nos termos da denúncia. Passo ao cálculo das penas.

O réu não ostenta antecedentes criminais e era menor de vinte e um anos na data do flagrante, mas a grande quantidade de droga, bem como o alto grau de toxicidade de parte considerável das drogas apreendidas, centenas de porções prontas para comercialização, incluindo cocaína, com potencial de dano difuso à saúde pública devido ao grande número de usuários faz incidir a regra do artigo 42 da Lei nº 11.343, afastando a aplicabilidade da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, excluído o requisito subjetivo previsto em caráter excepcional para essa regra de cálculo da pena. A circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, deve ser sopesada pela atenuante genérica de menoridade relativa ao tempo do fato, prevalecendo a pena base em patamar mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Não é aplicável a circunstância agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal, sustentada pelo Ministério Público em alegações finais, por se tratar de hipótese adstrita ao concurso de agentes.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, e o tempo de prisão descontado desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal não é compatível com a quantidade de pena aplicada e a gravidade da conduta, ponderados os mesmos fundamentos da dosimetria da pena, tratando-se de conduta de consequências diferenciadas que atenta seriamente contra a ordem pública e acarreta manifesto risco à ordem e segurança pública, fomento de diversas atividades criminosas ainda mais graves, a demandar tratamento legal diferenciado, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta pelo criminoso que se dispõe a distribuir drogas em bairro residencial densamente habitado, de modo a expor a risco não só os usuários como potenciais adquirentes de drogas ilícitas, mas principalmente todos aqueles que, alheios à sua atividade criminosos, são obrigados a conviverem diariamente sob a nefasta ameaça do tráfico de drogas.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, por não existir prova da condição econômica do condenado, nos termos do artigo 60 do Código Penal. Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar Richard Yuri Guimarães da Silva Felipe, qualificado à f. 9, menor de vinte e um anos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003).

O réu foi preso em flagrante, respondeu preso ao processo e subsistentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme decidido no curso da ação penal, não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 8072/90. Para efeitos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA